

1503789-06.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... e tinham em depósito, para fins de tráfico, as substâncias entorpecentes apreendidas, devendo prevalecer os depoimentos prestados pelos policiais civis por serem coerentes e precisos, até porque eles não conheciam os réus e não tinham motivo para incriminá-los caso eles fossem inocentes. De acordo com a jurisprudência: "Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1503789-06.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324385 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Réu:

LEILSON CHIQUETO DA ROCHA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 29 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

20/06/2022

Controle nº 2021/001292

Réu Preso

Aos 20 de junho de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Rossana Azevedo Inacarato, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 13:30h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra LEILSON CHIQUETO DA ROCHA e MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PINHEIRO por infração ao Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 29 "caput" do(a) CP(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes o réu e presente a Drª Tatiana Elisa Marão Beraquet, Defensora Pública. Certifico que as Defesas realizaram entrevista prévia individual com os réus através de reunião no Software Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foram ouvidas as testemunhas Policial Civil

Aprigio Carlos da Silva Neto, Roberto Gurgueira Nogare e os réus interrogados. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito que: "MM Juiz: Os réus LEILSON CHIQUETO DA ROCHA e MARCOS VINICIUS DOS SANTOS PINHEIRO foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal, e estão sendo processados pelos fatos descritos na Denúncia, a qual me reporto. Os acusados foram devidamente notificados as fls. 119/120, tendo apresentado Defesa Preliminar as fls. 122/124 e 137/138. A Denúncia foi recebida em todos os seus termos, conforme r. decisão de fls. 130/132. Os acusados foram citados (fls. 170 e 173). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo os réus interrogados. Não há nos autos qualquer nulidade que impeça o julgamento final. Feito esse breve relato, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente. A materialidade vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 14, bem como pelos Laudos de Constatação de fls. 47/53 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 95/98, que comprovam se tratar de 97 (noventa e sete) porções de Tetrahydrocannabinol (THC); 10 (dez) porções de Tetrahydrocannabinol (THC); 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína; 183 (cento e oitenta e três) porções de cocaína, na forma de "crack"; 14 (quatorze) porções de cocaína; 78 (setenta e oito) porções de cocaína, na forma de "crack"; e 15 (quinze) porções de porções de Tetrahydrocannabinol (THC), as substâncias entorpecentes encontradas em poder dos acusados. No que diz respeito à autoria, o acusado MARCOS VINICIUS, durante a fase investigatória (fl. 09), negou a prática do crime, dizendo que foi até o local apenas para comprar uma porção de "maconha" para o seu consumo pessoal e que tóxico apreendido não lhe pertencia. Já o corréu LEILSON, em solo policial (fl. 10), admitiu que guardava as drogas, alegando que estas não lhe pertenciam, pois passava por necessidade financeira. Afirmou também que MARCOS não tinha qualquer relação com o tóxico apreendido. Em Juízo, LEILSON negou a prática do crime e a propriedade da substância entorpecente. Disse que é amigo de MARCOS desde criança, sendo que, na data dos fatos, encontrou-se com MARCOS para juntos fumarem um cigarro de maconha. Afirmou que foram até o local para pegar a droga de um menino conhecido por "Magrinho", sendo que "Magrinho" falou para eles esperarem no quarto que ele já voltava e então "Magrinho" foi embora. Como "Magrinho" demorou para voltar, eles resolveram sair da residência, sendo que, quando desciam a escada, eles foram surpreendidos pelos policiais. Alegou que foram obrigados a deitar no chão onde havia diversas porções de droga e foram fotografados pelos policiais. Acrescentou que, na fase policial, fez uso do direito de permanecer em silêncio e que quem o levou até o local foi o corréu. MARCOS VINICIUS, por sua vez, alegou que estava na praça em frente à sua casa quando LEILSON chegou e o convidou para fumarem um "baseado". Após, foram até o imóvel em questão, onde foram surpreendidos pelos policiais. Afirmou que foram direto a este local para comprarem maconha, mas não sabia que ali vendia droga. Disse que estava sem dinheiro e que acompanhou LEILSON apenas para fumar um "beck". Conforme se verifica, as versões apresentadas pelos acusados são contraditórias e não convencem, devendo ser afastadas. O policial civil Aprigio Carlos da Silva Neto afirmou que receberam informações de que um imóvel situado no bairro Cidade Singer era utilizado para armazenamento de substâncias entorpecentes para serem comercializadas. Esclareceu que no referido bairro existem vários pontos de venda de drogas, sendo que o local indicado se tratava de uma residência com cômodos disponíveis para locação, tendo ingressado no quarto ocupado pelos réus, sendo que, na parte superior, surpreendendo os dois acusados manuseando porções de drogas, onde também apreenderam diversas porções de maconha, cocaína e "crack". Informou ainda que, em poder do réu LEILSON, foi apreendido um kit de drogas, contendo porções de maconha, cocaína e "crack". Na ocasião, o réu MARCOS alegou que estava no local para comprar "maconha" para o seu uso. Tais fatos foram confirmados pelo

policial civil Roberto Gurgueira Nogare, que acrescentou que o local se tratava de um cortiço e, conforme informação recebida, estava desocupado e era utilizado por traficantes. Disse que no cômodo havia apenas um colchão e uma mala, sendo que os réus manuseavam drogas no chão. Também afirmou que o réu MARCOS alegou que pretendia apenas comprar maconha para o seu consumo pessoal, enquanto LEILSON lhes disse que guardava o entorpecente para outra pessoa, pois passava por dificuldades financeiras. Assim, pelas provas produzidas, não há dúvida de que os acusados, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, as substâncias entorpecentes apreendidas, devendo prevalecer os depoimentos prestados pelos policiais civis por serem coerentes e precisos, até porque eles não conheciam os réus e não tinham motivo para incriminá-los caso eles fossem inocentes. De acordo com a jurisprudência: "Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena bem aplicada. Possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a fixação do regime aberto, Recurso parcialmente provido." (TJSP - Apelação Criminal nº 0007214-53.2018.8.26.0635 - 10ª Câmara - Rel. Francisco Bruno - j. 13 de fevereiro de 2020). "Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06 Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório Materialidade e autoria devidamente comprovadas Fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena Incabível Pena e regime mantidos Recurso desprovido". (TJSP - Apelação Criminal nº 1503855-27.2018.8.26.0536 - 7ª Câmara - Rel. Freitas Filho - j. 1º de julho de 2020). Frise-se ainda que as circunstâncias da prisão, a grande quantidade e variedade de tóxico apreendido (incompatível com o consumo para uso próprio) e a forma como este se encontrava acondicionado, isto é, em porções prontas para a venda, deixam claro que a droga manuseada pelos acusados e se destinava à comercialização. Por outro lado, o fato de os acusados alegarem ser usuários de substância entorpecente em nada altera a imputação que lhes é feita, pois é comum usuários se dedicarem ao tráfico para manter seu próprio vício. Também é importante destacar LEILSON, na fase policial, admitiu que guardava a droga no local, sendo que certo os policiais ouvidos, de forma unânime, informaram que os dois estavam juntos no quarto manuseando as porções de substância entorpecente, de forma ambos devem responder pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, para a configuração do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, não se exige que o agente seja preso no ato da mercancia. Este é de conteúdo múltiplo ou variado, bastando, para sua caracterização, a prática de uma das condutas descritas. Conforme entendimento jurisprudencial: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INTENÇÃO DE TRAFICAR 329G (TREZENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS) DE MACONHA APREENDIDOS COM O AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA PRÁTICA DE UMA DAS DEZOITO CONDUTAS RELACIONADAS A DROGAS PARA QUE HAJA A CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO PENAL.

1. "O crime de tráfico

de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017).

2. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp 1807400 / RS - Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. 15 de agosto de 2019). "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da lei Antitóxicos (atual art. 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347). Portanto, diante da prova inequívoca da autoria e da materialidade, requeiro a condenação dos acusados nos exatos termos da Denúncia,

fixando ao acusado LEILSON pena superior ao mínimo em razão de seus antecedentes criminais e por ser reincidente específico (cf. fls. 54/55 e 56/57), sendo que, em relação ao réu MARCOS, apesar de ser tecnicamente primário (cf. fls. 58/59), a grande quantidade e variedade de tóxico apreendido impede o reconhecimento de causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Por fim, requeiro seja fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena por ser o delito de tráfico equiparado a crime hediondo, sendo este o único capaz e suficiente para a reprovação e prevenção no caso em questão, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90. " Dada a palavra ao Defensor, o qual disse que: "MM. Juiz: LEILSON CHIQUETO DA ROCHA, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente à conspícua presença de Vossa Excelência, intermediado por seu advogado e bastante procurador subscrito, com fulcro no artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS na forma de MEMORIAIS, pelos argumentos de fato e direito a seguir expostos:

#### I - ESCORÇO FÁTICO

Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de novembro de 2021 (segunda-feira), por volta das 15h30, na Rua 03, 227, Vila Aeroporto, nesta cidade e comarca, LEILSON CHIQUETO DA ROCHA, qualificado a fls. 14 e 16, e MARCOS VINICIUS DOS SANTOS PINHEIRO qualificado a fls. 15 e 17, agindo em concurso e com unidade de desígnios, cada qual fazendo sua a ação do outro, traziam consigo e tinham em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 97 (noventa e sete) porções de Tetrahydrocannabinol (THC), pesando 344g ( trezentos e quarenta e quatro gramas) de massa líquida, 10 (dez) porções da mesma substância, pesando 63,2g (sessenta e três gramas e dois decigramas) de massa líquida, todas acondicionadas em invólucros plásticos fechados por pressão; 45 (quarenta e cinco) porções de Cocaína, pesando 19,1g (dezenove gramas e um decigrama) de massa líquida, acondicionados em microtubos do tipo "eppendorf"; 183 (cento e oitenta e três) porções de Cocaína em forma de Crack, pesando 13,4g (treze gramas e quatro decigramas) de massa líquida, acondicionados em microtubos plásticos do tipo "eppendorf"; 14 (quatorze) porções de Cocaína, pesando 6g (seis gramas) de massa líquida, acondicionadas em microtubos do tipo "eppendorf"; 78 (setenta e oito) porções de Cocaína em forma de Crack, pesando 5,5g (cinco gramas e cinco decigramas) de massa líquida, acondicionados em microtubos do tipo "eppendorf"; e 15 (quinze) porções de porções de Tetrahydrocannabinol (THC), pesando 53,4g (cinquenta e três gramas e quatro decigramas) de massa líquida, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10/11. Por estes motivos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, c.c. o artigo 29 do Código Penal.

#### III - BREVE ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO E DAS PROVAS AMEALHADAS

##### A - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS

Em matéria de elementos de convicção, necessário se faz salientar informação, ou melhor, ausência de informações, nos depoimentos dos agentes policiais, a saber, APRIGIO CARLOS DA SILVA NETO e ROBERTO GURGUEIRA NOGARE. Quando ouvidos em solo policial, bem como em juízo, os respectivos agentes deixaram de esclarecer de que natureza fora as investigações que teriam justificado a incursão ao endereço em que se deu a prisão dos réus em questão. Veja-se que, às fls. 7 e 8, ambos declararam que "após trabalho de investigação apuraram que o endereço a rua 03, numeral 227, do bairro Cidade Singer, nesta cidade, estaria sendo utilizado para armazenamento de substância entorpecente com destino a comercialização". Entretanto, nada fora juntado aos autos, nada fora minimamente documentado, a respeito da origem desta investigação ou do teor desta, nenhum dado que conferisse à incursão as fundadas razões que um Estado Democrático de Direito reclama.

##### II - DA ILEGALIDADE DA PRISÃO E OUTRAS VIOLAÇÕES A DIREITOS CONSTITUCIONAIS E PRESCRIÇÕES DO CPP

Assim, a investigação policial que originou os autos em questão foi deflagrada por suposta "investigação prévia" (fls. 8 e 7), a qual teria apontado que o local estaria sendo utilizado para armazenamento de substância entorpecente com destino a comercialização. Todavia, urge salientar, nada foi esclarecido a respeito de como se deu a dita investigação que antecedeu a incursão policial no imóvel, denominado

de "cortiço". Vossa excelência, em decisão de fls. 130, oficiou à Autoridade Policial, para que informasse como se deu o início da investigação mencionada. Quedou-se silente, contudo, a Autoridade Policial, não fornecendo quaisquer esclarecimentos a respeito dos meios e das informações em que se embasaram para adentrar o local e realizar a apreensão dos entorpecentes. Ora, o só fato de, no momento da incursão policial, o imóvel estar – supostamente – com as portas abertas, não descaracterizava a sua natureza de domicílio. Fosse assim, nenhum cidadão poderia deixar a própria garagem aberta, pois então se poderia presumir, segundo a lógica dos agentes policiais, que "ninguém aí demonstrasse propriedade". A bem da verdade, como salientado pelo advogado Marcelo Rosa Maia, em sua manifestação na audiência de custódia, tal incursão se deu desprovida de qualquer legitimidade e legalidade, pois tratava-se de imóvel localizado em região periférica, cujos moradores e vizinhos são de baixa renda e, portanto, presume-se o abandono do imóvel que, diga-se de passagem, por ser um sobrado, não teria características de cortiço e, ainda que o fosse, a legislação pátria, bem como a jurisprudência, exigem que seja o imóvel individualizado e devidamente justificada a entrada no local. Ante a ausência de quaisquer justificativas plausíveis para a incursão, ou seja, NÃO APRESENTANDO QUAISQUER ELEMENTOS CONCRETOS NO QUE TANGE ÀS FUNDADAS RAZÕES, há que se observar a ilegalidade da incursão policial, desprovida de mandado ou de justificativas legalmente válidas. É, portanto, evidente a ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, uma vez que os policiais VIOLARAM O IMÓVEL em questão, SEM O CONSENTIMENTO de qualquer dos moradores do dito cortiço, e SEM A DEVIDA ORDEM LEGAL (Mandado de Busca e Apreensão). Ou seja, há evidente contrariedade ao texto expresso da lei, mais especificamente, o artigo 240 (busca domiciliar) bem como ao artigo 243 (mandado de busca) do Código de Processo Penal, que prescreve os requisitos necessários para que se leve a efeito a busca domiciliar. Urge destacar que o Supremo Tribunal Federal definiu, em REPERCUSSÃO GERAL, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Vejamos a ementa: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO, SEM UMA JUSTIFICATIVA PRÉVIA CONFORME O DIREITO, É ARBITRÁRIA. NÃO SERÁ A CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, POSTERIOR AO INGRESSO, QUE JUSTIFICARÁ A MEDIDA. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,

devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, j 05/11/2015 , Tribunal Pleno, DJe-093)”

A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1º do CPP – devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Sobre a delimitação das circunstâncias que indicariam a existência dessas fundadas razões, assinalou o Ministro Relator que:

“É amplo o leque de elementos que podem ser utilizados para satisfazer o requisito. O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio. No entanto, ao ouvir gritos de socorro e ruídos característicos de uma briga vindos de dentro de uma residência, o policial tem fundadas razões para crer que algum crime está em andamento no ambiente doméstico. Não se deve exigir que busque confirmação adicional para agir. Por outro lado, provas ilícitas, informações de inteligência policial – DENÚNCIAS ANÔNIMAS, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que NÃO TÊM FORÇA PROBATÓRIA EM JUÍZO NÃO SERVEM PARA DEMONSTRAR A JUSTA CAUSA”.

Deve haver, assim, uma causa provável, ou seja, uma justa causa para o ato invasivo, a partir da segura verificação, posto que superficial, da existência de fatos ou de circunstâncias que permitam qualquer pessoa acreditar ou ao menos suspeitar, com base em elementos concretos, que um crime esteja ocorrendo no interior do domicílio. No mesmo sentido os ensinamentos de Celso Delmanto:

“[...] o flagrante que constitui verdadeira emergência para que se admita a violação domiciliar a qualquer hora do dia ou da noite sem prévia autorização judicial. Seriam hipóteses, por exemplo, de flagrante de crimes permanentes como a extorsão mediante sequestro, em que há a necessidade de prestar-se socorro imediato à vítima que corre perigo de vida etc., o que não se verifica em casos de crimes permanentes como a simples posse de entorpecentes ou de armas ilegais. [...] Não obstante se possa alegar que esse entendimento poderia obstaculizar a ação policial, este é o preço que se paga por viver em um Estado Democrático de Direito, que deve tomar todas as medidas para restringir, ao máximo, a possibilidade de arbítrios e desmandos das autoridades policiais por mais bem intencionadas que possam elas estar. (Código Penal Comentado. 6. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 324).”

Devemos levar em conta que o indivíduo é sujeito de direitos e dispõe de garantias legais e constitucionais, cuja inobservância pelos agentes públicos, além de eventualmente induzir-lhes responsabilidade penal por abuso de poder, pode gerar ABSOLUTA NULIDADE da prisão realizada mediante violação a domicílio. O próprio Código de Processo Penal reitera a cláusula constitucional quando, em seu artigo 283, §2º expressamente aponta a necessidade de serem respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. O réu NÃO AUTORIZOU A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO, e SEQUER FOI OBSERVADO EM FLAGRANTE DELITO, SENÃO APÓS A INVASÃO e diligência policial já no interior do imóvel (o que não torna válida a invasão, pois que NÃO FOI JUSTIFICADA POR FUNDADAS RAZÕES PRECEDENTES À VIOLAÇÃO). Os agentes realizaram verdadeiro FISHING EXPEDITION dentro do imóvel e no interior dos cômodos, como comprovam seus próprios depoimentos. Tudo isso vem a deixar patente estar a prisão, bem como a operação como um todo, inquinada de violações a direitos e às prescrições do Código de Processo Penal. Afinal, repise-se: não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Ademais, em juízo, restou igualmente patente que a suposta denúncia anônima

era em relação ao local e não em relação a pessoas determinadas. Que há contradição no depoimento dos Policiais se outros moradores do local foram abordados. E há notícias de que uma terceira pessoa teria se evadido do local.

### III - DA CONFISSÃO INFORMAL E DO INTERROGATÓRIO EM SOLO POLICIAL

No que se refere à confissão informal, é absolutamente inadmissível no âmbito do devido processo legal. AURY LOPES JÚNIOR assevera que a confissão extrajudicial é de todo inadmissível:

"Com isso, concordamos com o autor quando afirma que perdeu completamente o sentido a distinção entre confissão "judicial" e "extrajudicial", pois somente pode ser valorada a confissão feita em juízo. Perdeu sentido, assim, o art. 199 do CPP. Ademais, a confissão eventualmente feita na fase policial não será juntada ao processo, dada a vedação prevista no art. 3º-C, § 3º, do CPP, que consagrou a exclusão física dos autos da investigação. Lembrando que esse dispositivo foi suspenso pela liminar do Min. FUX, mas que poderá ter vigência a qualquer momento." Neste mesmo sentido o precedente abaixo transcrito, vejamos:

"HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. WRIT NÃO CONHECIDO. PROVA ILÍCITA. CONFISSÃO INFORMAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DESENTRANHAR DOS AUTOS OS DEPOIMENTOS CONSIDERADOS IMPRESTÁVEIS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 5º, INCISOS LVI E LXIII. 1 - Torna-se inviável o conhecimento de habeas corpus, se o pedido não foi enfrentado pelo Tribunal de origem. 2 - A eventual confissão extrajudicial obtida por meio de depoimento informal, sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito. 3 - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 22.371/RJ, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 31/03/2003, p. 275)."

Ademais, o réu foi ouvido sem a presença de advogado, sequer constando a sua assinatura no Termo de Interrogatório, às fls. 10.

### V - DOS PEDIDOS

Por todo o exposto requer:

A. Que seja o réu absolvido, em razão da inexistência de provas hábeis a ensejar a sua condenação, vez que maculadas por violação a domicílio, dentre outras ilegalidades apontadas (Art. 386, inciso V do CPP);

B. Por fim, que o réu possa, frente a eventual condenação, recorrer em liberdade, vez que não há motivo ensejador de medida cautelar mais severa.

Nestes termos, pede e espera deferimento."

Dada a palavra à Defensoria Pública, a qual disse que: "MM Juiz: A DPE requer seja o réu absolvido da imputação por falta de provas acerca da autoria delitiva. Com efeito, ao ser interrogado na delegacia e em Juízo, MARCOS VINICIUS negou o delito com veemência. Explicou que no dia dos fatos, encontrou com o acusado Leilson que o chamou para fumar maconha. Eles foram fumar maconha no local dos fatos. A droga não era do acusado e estava no quarto. Não conhece Magrelo. Ele não estava no quarto das drogas. Ele estava no quarto do lado de onde estavam drogas. Os policiais invadiram o cortiço e os abordaram. A prova coligida aos autos não infirmou sua negativa, pois se restringiu à oitiva dos policiais civis, que prestaram relatos inseguros e contraditórios. O PC Aprígio disse que fez diligências no local que tinha movimentação de tráfico. A denúncia recebida falava que era uma residência que armazenava drogas. O local era conhecido para armazenar drogas. Disse que diversos pontos do bairro Cidade Singer são usados para armazenar entorpecentes. Era um sobrado, ingressaram e em cima acharam os dois réus. Sobre o imóvel, disse que diversas pessoas tinham acesso para locação. Quando entrou viu, que havia drogas no chão, no colchão e numa mala. O Marcos Vinícius disse que estava lá para comprar maconha. Leilson disse que guardava entorpecentes, pois enfrentava dificuldades financeiras. Leilson tinha um kit de drogas. Ambos manipulavam entorpecentes. Não se lembrou de como chegou a denúncia. Não descreveu as drogas apreendidas. Fez diligências no local e entrou. No quarto havia drogas espalhadas. Afirmou que existia um portão no local que estava aberto. A porta que dava acesso aos quartos estava aberta. Contou que no quarto dos fundos, tinha um casal, mas não ingressou lá, pois não lhe pareciam suspeitos. Chegou a abordar um indivíduo na

entrada do imóvel, mas o liberou. Não o trouxe para acompanhar as diligências, pois não sabia o que encontraria no local. Não lembrava se os réus tinham dinheiro com eles. O PC Juliano disse que recebeu denúncia sobre o local, cortiço desocupado e que estava aberto. Era ponto de armazenamento de drogas e pois percebeu movimentação no piso superior do imóvel. Não havia ninguém no local. Passou pela porta aberta ao imóvel cuja janela dava acesso à rua. Ambos os réus mexiam em entorpecentes no chão. Não havia denúncia em relação às pessoas. Abordado, Leilson disse que recebia dinheiro para guardar droga. Marcos Vinícius disse que tinha ido ao local comprar drogas. Eles não tinham dinheiro. Ao contrário de seu colega de operação, o PC Juliano disse que não abordou ninguém no local. A denúncia era em relação ao imóvel e chegou pelo disque denúncia. O bairro é tomado pelo tráfico de drogas. Depois disse que a denúncia chegou durante diligências de policiais, mas não se lembrava de como a denúncia chegara, pois disse que essa informação pode colocar em risco vidas humanas. Ao ser interrogado, Leilson relatou que é amigo de Marcos e que no dia dos fatos, encontrou Marcos para fumar maconha. Ambos foram ao local, que fica a 4 ruas da casa dele. Eles foram aguardar maconha do rapaz que vendia. Ouviram barulho e logo chegaram os policiais. Entraram no quarto e os policiais acharam as drogas. Foram presos descendo da escada. Nesse cenário, os relatos do policiais se mostraram inseguros e contraditórios. Enquanto o primeiro policial ouvido relatou que abordou um casal e um rapaz, além dos réus, o PC Juliano disse só abordou os réus. Os policiais não descreveram as drogas apreendidas e nem o local em que elas estavam. O réu não foi surpreendido na posse de qualquer entorpecente, apenas o corréu Leilson tinha kits de drogas consigo, segundo os investigadores. Os investigadores disseram que a denúncia cuja fonte é desconhecida não diziam nada dos acusados, apenas sobre o local. Assim, o que se tem é a presença do réu em um imóvel com vários cômodos. Não houve investigação a respeito do envolvimento do réu com drogas. Ele é primário, sem antecedentes. Negou os fatos desde que ouvido na delegacia. Nenhum ato de mercancia foi visto. E segundo narraram os investigadores, o imóvel estava aberto, de modo que é possível que as drogas armazenadas lá pertencessem a outra pessoa qualquer do bairro. Nesse contexto probatório, não é possível imputar a posse das drogas apreendidas ao réu Marcos Vinícius. Assim, por força do princípio do in dubio pro reo, requer seja ele absolvido do delito, com base no art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer a concessão da redução da pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, eis que presentes os requisitos legais. Marcos é primário, sem antecedentes criminais. Não há qualquer indício de que se dedique a atividades criminosas. Por consequência, requer ainda a fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por medidas restritivas de direitos, ante a presença de circunstâncias favoráveis, como medida de Justiça. Frise-se que a vedação da substituição da pena por medidas restritivas de direitos aos condenados por tráfico de drogas prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 foi suspensa pela resolução 05 do Senado Federal de 16/02/12, em razão da declaração de inconstitucionalidade da disposição por decisão do Supremo Tribunal Federal, por violação à individualização da pena. Também é vedado o estabelecimento do regime prisional mais gravoso do que o previsto em lei com base na gravidade abstrata do delito, conforme entendimento assente nos Tribunais Superiores. No caso em tela, o regime aberto é medida adequada e proporcional à escassa gravidade do fato, pois o réu preenche todos os requisitos do art. 33, parágrafo 2º. letra c do CP, sendo suficiente para prevenção e repressão ao delito." A seguir, pelo MM. Juiz foi dito:

"Leilson Chiqueto da Rocha e Marcus Vinicius dos Santos Pinheiro estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Feito regularmente processado.

Em audiência realizada nesta data foram ouvidos os policiais que participaram da prisão, assim como os réus foram interrogados.

Decido.

Materialidade comprovada através do auto de prisão em flagrante, bem como pelos laudos de fls. 47/53.

A autoria também é inegável.



Inicialmente, ressalte-se que ambos os policiais civis prestaram depoimentos coerentes e detalhados, repetindo em juízo o que disseram no flagrante, ou seja, que foram investigar denúncia de tráfico e entrando em um local aberto, viram ambos os réus mexendo nas diversas drogas.

Aliás, resta ressaltar que não há qualquer prova, seja testemunhal ou documental, de que o imóvel fosse "domicílio", como alegado pela defesa. Os próprios depoimentos dos réus, ressalte-se, contradizem essa tese.

No flagrante, Leilson disse que guardava droga para terceira pessoa, enquanto Marcus disse que foi até lá para comprar maconha.

No mesmo sentido, os termos de interrogatório durante o flagrante (fls. 9/10).

Em juízo, contudo, os réus apresentaram versões absolutamente diferentes e, portanto, irreais.

Leilson disse que se encontrou com Marcus e que ambos decidiram comprar maconha.

Foram primeiro até um local próximo a sua casa e não encontraram a droga na "biqueira" que fica "no meio da rua". Então, Marcus mencionou sobre o outro local, o "sobrado verde" e ambos foram para lá. Subiram e encontraram o traficante, conhecido por "Magrelo" que pediu que os dois aguardassem lá até que ele voltasse, não obstante as drogas estivessem espalhadas pelo local. Resolveram sair e, quando estavam indo embora, foram surpreendidos pelos policiais, que os pegaram já quando estavam descendo a escada. Foram forçados a subir de novo e, então, presos.

Marcus, por seu turno, disse que eles já tinham a droga e que estavam procurando um local para fumar. Negou que tivessem ido procurar droga em outra "biqueira" ou que tivessem ido até o "sobrado verde" para comprar entorpecentes. Disse, ainda, não saber quem é "Magrelo".

A absoluta divergência entre os interrogatórios reforça, assim, o teor probatório dos depoimentos dos policiais.

No mais, considerando que ambos estavam manuseando as drogas, evidente que o tráfico de drogas era praticado pelos dois.

Passo a dosar as penas, observando que Leilson é reincidente específico (fls. 54/55).

Para ambos os réus, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Com relação a Leilson, pela reincidência específica, aumento a pena em 1/5, para 6 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Inviável a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33.

Também em função da reincidência, bem como pela gravidade do crime de tráfico, fixo o regime inicial fechado, mantida no mais a prisão preventiva, já que subsistem os requisitos legais.

Quanto a Marcus, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Presente a causa de redução, considerando a diversidade de drogas bem como sua quantidade, reduzo a pena em metade, para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Tendo em vista a gravidade do delito, que está diretamente ligado a outros, como lavagem de dinheiro e organização criminosa, por exemplo, fixo o regime inicial semiaberto. Estas mesmas razões impedem, pela insuficiência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Isso posto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia e condeno o réu Leilson Chiqueto da Rocha à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 600 dias-multa, de valor unitário mínimo e o réu Marcus Vinicius dos Santos Pinheiro à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 250 dias-multa, de valor unitário mínimo, ambos pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11343/06.

Marcus encontra-se solto e, não havendo motivos neste momento para a decretação da prisão preventiva, assim poderá recorrer.

Custas de 100 Ufesp's "

Certifico e dou fé que tornei pública a r. Sentença. Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e

achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.